



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

SENTENÇA

Vistos, etc.

Mariana da Silva Lima, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta, no dia 28 de junho de 2017, na Rua do Seu Olhar, 151, a acusada, juntamente com MIKE DE DEUS HONORATO guardava, para fins de tráfico, 80 quilogramas de maconha.

Determinada a notificação da ré (fls. 213/214), houve resposta (fls. 272/282) e a denúncia foi definitivamente recebida em audiência, sendo colhida a prova oral e a ré interrogada, tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 293/295.

É o relatório.

Decido.

A procedência da ação é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas.

A natureza do entorpecente, bem como sua quantidade, absolutamente incompatível com a posse para uso próprio, evidenciando a destinação a terceiros, caracterizando o tráfico, está demonstrada pelo laudo pericial.

E que a droga foi encontrada pelos policiais na casa da mãe da ré, onde ela estava, foi informado pelos agentes e admitido pela ré, restando incontroverso.

Não resta dúvida, ainda, de que a ré sabia, sim, que a droga estava guardada ali, bem como a natureza do entorpecente, como restou informado por ambos os policiais em juízo.

E não há nada de concreto nos autos contra os policiais ouvidos, nem a indicação de qualquer razão que teriam para cometerem crime e colocarem suas carreiras em risco, imputando à ré, a quem sequer conheciam, crime que não tivesse praticado, inexistindo assim razão para dar às palavras destes agentes públicos menos valor que às de qualquer outro cidadão.

Aliás, soma-se ao que foi informado pelos policiais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

que foi dito por ela quando da abordagem, o que foi dito também na interceptação, quando ela falou a seu companheiro Mike para retirar a droga dali, evidenciando que sabia ser ilícito, bem como o alertava da presença de veículo na rua que poderia ser de policiais.

Por fim, a afastar qualquer margem para dúvida, há a integral confissão da ré em juízo, restando a acusação incontroversa.

Importante observar que, ainda que a droga não fosse da ré, tendo ela apenas admitido guardá-la, mesmo que por pouco tempo, de qualquer forma praticou o tipo penal de tráfico, sendo de rigor sua condenação.

E, certa a condenação pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06, passo a dosar a pena.

Na fase do artigo 59 do Código Penal, e atento ao disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, tenho que é necessária a fixação da pena base acima do piso legal.

De fato, a enorme quantidade de droga, sendo 80 quilogramas, é suficiente a dezenas de milhares de porções, podendo atingir um enorme número de usuários, dando diferenciada relevância para o caso concreto. Não se pode, portanto, punir este delito da mesma forma que se tivesse sido apreendido com o réu apenas uma dúzia de porções, por exemplo.

Assim, no caso dos autos, fixo a pena base da ré em oito anos de reclusão, patamar que não representa um avanço de nem um terço no intervalo previsto para o delito, que é de 5 a 15 anos.

Porém, na segunda fase da dosimetria, a presença das atenuantes da menoridade e da confissão, esta completa e sincera, merecendo ser valorizada, compensam o aumento anterior, devendo a pena da ré retornar ao mínimo legal, a saber, cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, estes no mínimo legal, à minguia de outras informações sobre a situação financeira da acusada.

A ré é primária, sem antecedentes, e não há comprovação definitiva de que fosse envolvida com organizações ou outras práticas criminosas. Além disso, ao que consta, não era ela a dona da droga, mas apenas a guardou, ocasionalmente, para outra pessoa. Não vejo, assim, óbice ao benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Quanto ao montante da redução, dadas as peculiaridades do caso concreto, envolvendo grande quantidade, mas se mostrando a circunstancialidade da ação da ré, tenho como razoável e suficiente a redução da pena em metade, finalizando a pena da ré em dois anos e seis meses de reclusão e 250 dias-multa.

Quanto às questões da liberdade provisória (o que alcança também o direito a recorrer solto), da possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade e do regime inicial da sanção, observo que o Supremo Tribunal Federal vem, ainda que de forma não unânime (havendo valiosíssimos votos divergentes), afastou a inflexibilidade das disposições legais expressas (vedação da liberdade e das penas restritivas, bem como regime inicial sempre fechado).

E as razões de tais entendimentos vêm bem esclarecidas na seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma suprallegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 279-333)

Ou seja, é evidente que um dos principais fundamentos do afastamento daquelas disposições legais inflexíveis foi a preservação do poder/dever de individualização das penas, nem de longe se podendo disso extrair que todo e qualquer tráfico de entorpecentes deva ser considerado como tendo a mesma gravidade e pelos mesmos critérios que qualquer outro delito, tais como um simples furto ou estelionato, por exemplo.

Ora, não se pode negar que tanto o Constituinte como o legislador ordinário sempre demonstraram que o tráfico de entorpecentes é um crime muito grave, e merece ser combatido com especial rigor. Vide nesse sentido não só os dispositivos atacados das Leis nº 11.343/06 e 8.072/90, como também os incisos XLIII e LI do artigo 5º da Constituição Federal.

Desta forma, tenho que a melhor interpretação das decisões do Supremo Tribunal Federal, com o necessário e imprescindível respeito à vontade da sociedade expressada pelo legislador é a de que o sentido daquelas determinações específicas (maior rigor) deva ser a base de aplicação das penas para o crime de tráfico, mas com a flexibilidade de que, em situações diferenciadas de menor gravidade, se possa, em caráter excepcional, abrandar as sanções aplicáveis.

O tráfico de entorpecentes é uma atividade extremamente lucrativa, e a sanção para tal delito deve ser proporcional ao benefício que ele proporciona a quem o pratica, sob pena de prejudicar o objetivo da pena de dissuadir deste tipo de conduta.

Agir de outra forma, tratando o tráfico de drogas exatamente pelos mesmos critérios que qualquer outro delito não hediondo ou equiparado implicaria em transformar em letra morta as disposições, orientações e princípios contidos na Constituição Federal sobre tal delito.

Porém, por outro lado, considerando o tempo de prisão cautelar e especialmente a confissão em juízo, denotando arrependimento, além da falta de notícias de envolvimento da ré com outros crimes, e as circunstâncias específicas da ação da ré, entendo que o caso dos autos é daqueles diferenciados que merecem um tratamento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

mais cauteloso, mostrando-se conveniente a concessão a ela de oportunidade de ressocialização, razão pela qual, excepcionalmente, concedo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no piso de um salário mínimo.

Por fim, considerando que a pena privativa de liberdade só será executada caso a ré descumpra as penas alternativas, o que, contrariando as razões que levaram ao favorecimento acima concedido, e denotaria personalidade comprometida e desmerecedora da confiança estatal, e considerando todo o antes mencionado sobre a gravidade e o tratamento diferenciado dado ao crime de tráfico, fixo como regime inicial da pena o semiaberto, posto que nesta hipótese estaria evidente a insuficiência do regime aberto, o qual na prática é cumprido na modalidade domiciliar sem maior fiscalização do cumprimento de suas condições, e pressupõe um senso de responsabilidade inexistente nesta situação.

Fixar outro regime mais favorável implicará na verdade em beneficiar a ré com modalidade de pena que na prática, pela falta de estrutura estatal (casa do albergado), será mais favorável que a própria pena restritiva de liberdade, o que é um contrassenso e implica na inocuidade da aplicação da lei penal.

Por outro lado, no caso de cumprimento da pena substituta, a fixação de tal regime menos permissivo não implicará em nenhum prejuízo à situação do acusado.

Isto posto, julgo a presente ação PROCEDENTE, para condenar **Mariana da Silva Lima**, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de dois anos e seis meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 250 dias-multa, estes no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta no piso de um salário mínimo.

Ante a pena aplicada, a ré poderá apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, o qual é considerado cumprido nesta data, comunicando-se.

Comunique-se nos autos de *habeas corpus* a presente decisão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA
3ª VARA CRIMINAL

Não havendo impugnação ao laudo pericial, inexistindo assim dúvida sobre a natureza da droga e considerando as precárias condições de acondicionamento destas substâncias nas Delegacias de Polícia, determino que caso ainda não tenha sido feito, **oficie-se, independente do trânsito em julgado, comunicando a autorização para incineração dos entorpecentes apreendidos.**

Custas pela condenada, na forma do artigo 4º, § 9º, *a*, da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2017.

Juiz de Direito: Dr. **Carlos Eduardo Lora Franco**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ciente:

Ministério Público:

Réu(s):

Defensor(es):